

1500125-05.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo César Ribeiro Meireles

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... escondida no mato. Alegou que realizava o tráfico de drogas por dificuldades financeiras. Afirmou que o dinheiro encontrado no carro era produto do tráfico de drogas. Alegou que incorria no tráfico há cerca de dois meses. Alegou que está arrependido.

Vale lembra que as afirmativas feitas pelos agentes policiais têm a presunção "juris tantum" de serem verdadeiras, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá 1ª Vara

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 2124-9664, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat1@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 15 de setembro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles. Eu, _____, Escr., lavrei este termo.

SENTENÇA

Processo nº:

1500125-05.2022.8.26.0621 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DA SILVA SANTOS

Juiz de Direito Dr.: Paulo César Ribeiro Meireles

VISTOS OS AUTOS.

GUILHERME DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Presentante do Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 16, §1, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta de 20 horas e 15 minutos, na Rua Antenor de Vasconcelos Cardoso, 650, bairro Vila Comendador, nesta cidade e Comarca Guaratinguetá-SP, trazia consigo, para fins de

consumo de terceiros, aproximadamente drogas consistentes em 554,5 g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e cinco decigramas) de Cannabis sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local supra, que o Réu, portava 01 (um) revólver, calibre 32, marca Taurus, com numeração suprimida, municiada com dois cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, o Réu realizava o tráfico de entorpecentes, quando foi surpreendido por policiais militares que faziam patrulhamento no local. Consta que a equipe policial avistou o Réu estacionar seu veículo (Fiat/Uno, cor vermelha, placas ER09995/Guaratinguetá), quando o Réu, ao avistá-la, trancou-o e empreendeu fuga, dispensando uma arma de fogo no caminho.

Ato contínuo, o Réu adentrou a residência de Ivair Ambrósio Tibúrcio, morador do bairro em questão, local no qual abandonou seu aparelho celular.

Em seguida, os policiais, com autorização do proprietário, adentraram a residência, quando localizaram o Réu e o submeteram à busca policial, momento no qual os milicianos lograram encontrar o montante de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) e a chave de seu veículo Fiat/Uno.

Consta ainda que, com a posse da chave do veículo mencionado, os policiais destrancaram o automóvel e, ao revistarem o automóvel, apreenderam a quantia de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) ao lado do freio de mão e uma sacola plástica contendo um tijolo de maconha (550,3 gramas) e mais três porções da mesma droga (52,16 gramas), embaixo do banco do motorista.

Consta que os milicianos conseguiram recuperar a arma de fogo dispensada pelo Réu durante a fuga, quando puderam perceber que ela se encontrava com numeração suprimida e municiada com dois cartuchos íntegros.

Ato contínuo, o Réu foi preso em flagrante delito.

Vieram aos autos Auto de Prisão em Flagrante Delito (págs. 01/03); Termos de Depoimento (págs. 04/06); Boletim de Ocorrência (págs. 09/13, 48/54); Auto de Exibição e Apreensão (págs. 14/16); Imagens de Identificação do Réu (págs. 27/32); Imagens dos Objetos Apreendidos (págs. 34/41); Laudo Pericial (págs. 44/46); Inquérito Policial (págs. 100/101); Folhas de Antecedentes Criminais (págs. 57/60, 144/146).

A denúncia foi recebida às páginas 105 a 108.

Convertida prisão em flagrante delito em prisão preventiva (págs. 74/78, 83/91).

O Réu apresentou defesa preliminar às páginas 110 a 113. Alegou que contesta a denúncia em todos os seus termos, alegando que provará durante a instrução criminal a sua inocência. Alegou que o Réu é menor de 21 anos, com endereço fixo, trabalho lícito e primário. Alegou que não há provas de que o Réu represente risco para a ordem pública. Alegou que as provas apresentadas não são suficientes para que ocorra a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva. Requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público se manifestou às páginas 123 a 125. Afirmou que o ato praticado pelo Réu atenta contra a ordem pública e causa insegurança da população. Afirmou que restou demonstrada sua periculosidade social, posto o porte de arma com numeração suprimida. Afirmou que não se encontram presentes condições autorizadoras da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Requereu a manutenção da denúncia e da prisão preventiva.

Confirmado o recebimento da enuncia (págs.128/130).

Indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva (págs.128/130).

Designada audiência de instrução e julgamento (págs.128/136, 140/143, 152/156).

Em petição diversa, o Réu requereu a restituição do carro apreendido em sua posse, alegando que este pertence à sua genitora (págs. 147/149), tendo o pedido sido indeferido (pág.164).

Em audiência, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação (págs. 158/159) sendo o Réu interrogado ao final (págs. 160/161).

Em alegações finais, o Doutor Promotor requereu a procedência do pedido, afirmando que a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas. Quanto à dosimetria

da pena, requereu o não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, haja vista que para a concessão da diminuição, o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Também requereu que a pena seja fixada acima do mínimo legal devido à quantidade de drogas. Além disso, requereu que o regime inicial de cumprimento de pena seja o fechado (págs. 176/180).

A defesa, por sua vez, em alegações finais, alegou que o Réu é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito. Alegou que não existem provas suficientes para embasar condenação. Subsidiariamente, requereu que seja aplicada a pena mínima, com a redução legal prevista no §4º, do artigo 33, da lei de entorpecentes. Requereu que seja aplicado o regime inicial mais brando (págs. 181/182).

Vieram-me conclusos os autos.

Foi convertido o julgamento em diligência para a vinda do laudo da arma e este veio, sendo aberta vistas às partes sobre e se tinham algo a acrescentar às suas alegações, os quais as ratificaram (págs. 183, 186/189, 194 e 197, respectivamente).

Este, em síntese, é o relatório.

FUNDAMENTO.

Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de tráfico dito praticado pelo Réu, que trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, aproximadamente drogas consistentes em 554,5 g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e cinco decigramas) de Cannabis sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também portava 01 (um) revólver, calibre 32, marca Taurus, com numeração suprimida, municiada com dois cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ausentes preliminares, quanto ao mérito, no que diz respeito à materialidade do delito, observamos que as substâncias entorpecentes foram constatadas como sendo realmente as drogas em questão, prévia e definitivamente, de acordo com o Laudo Pericial (págs. 44/46). Aliás, a materialidade também é comprovada por existirem Auto de Prisão em Flagrante Delito (págs. 01/03); Termos de Depoimento (págs. 04/06); Boletim de Ocorrência (págs. 09/13, 48/54); Auto de Exibição e Apreensão (págs. 14/16); Imagens de Identificação do Réu (págs. 27/32); Imagens dos Objetos Apreendidos (págs. 34/41); Inquérito Policial (págs. 100/101). Laudo da arma (págs. 186/9).

A autoria, por sua vez, é igualmente certa e indubitosa a partir do que nos autos consta, como veremos linhas a seguir.

I.A.T., afirmou que o Réu invadiu a sua casa. Afirmou que na frente de sua casa não tem portão, pois, este está quebrado. Afirmou que ao sair, encontrou dois policiais prendendo o Réu e algemando o seu filho. Afirmou que os policiais algemaram seu filho devido a este também estar na casa. Afirmou que não viu se o Réu portava armas ou drogas. Afirmou que conversou com os policiais e estes entenderam a situação, tendo soltado seu filho. Afirmou que os policiais fizeram uma revista em sua casa, tendo encontrado o celular do Réu no local. Afirmou que percebeu que o Réu invadiu sua casa devido a ter dois cachorros bravos na casa, tendo esses começado a latir ao perceberem a presença do Réu. Afirmou que perto da sua casa tem pontos de tráfico.

J.B.F.S.F., Policial Militar, afirmou que os policiais realizavam patrulhamento no local, ponto de tráfico, quando viram o Réu descer do veículo. Afirmou que a equipe policial abordou o Réu, quando este trancou o veículo e empreendeu fuga. Afirmou que os policiais o seguiram com lanternas, pois, o local tem pouca iluminação. Afirmou que, enquanto fugia, o Réu dispensou uma arma de fogo. Afirmou que um policial ficou vigiando o veículo. Afirmou que o Réu entrou na residência da testemunha e tentou se desvencilhar de um celular. Afirmou que a testemunha autorizou que os policiais abordassem o Réu. Afirmou que o celular foi encontrado e que o Réu não quis informar a senha. Afirmou que lograram encontrar a chave do automóvel e, ao abri-lo, foram localizados embaixo do banco porções de maconha e a quantia de cerca de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Afirmou que o Réu

já era conhecido no meio policial.

O Réu, GUILHERME DA SILVA SANTOS, em seu interrogatório, alegou que as drogas e o revólver pertenciam a ele. Alegou que o carro pertencia à sua mãe. Alegou que realmente entrou na casa da testemunha. Alegou que não dispensou a arma, estando esta escondida no mato. Alegou que realizava o tráfico de drogas por dificuldades financeiras. Afirmou que o dinheiro encontrado no carro era produto do tráfico de drogas. Alegou que incorria no tráfico há cerca de dois meses. Alegou que está arrependido.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelos agentes policiais têm a presunção "juris tantum" de serem verdadeiras, posto que estão à serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente caso.

Neste sentido:

"Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao processo." (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

Assim, observa-se que o referido delito restou devidamente caracterizado e o seu Autor corretamente identificado.

Primeiramente, cumpre observar que o crime de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 possui natureza múltipla, ou seja, sua tipificação descreve mais de uma conduta, em relação à mesma vítima, que neste caso é a saúde pública. Essa classificação é de suma importância, pois o tráfico não consiste em apenas no ato de vender drogas a alguém.

Nota-se que o Policial Militar foi categórico ao dizer que as drogas em questão foram encontradas no automóvel do qual o Réu saiu, trancou e empreendeu fuga, tendo, inclusive, um policial ficado de guarda do carro enquanto os outros perseguiam o Réu, conforme já transcrito.

Igualmente, o depoimento vem em conformidade com o que foi apreendido, de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão às páginas 14 e 16.

Nesse diapasão, observo também que o Réu é confesso, de forma que o delito restou devidamente comprovado. Ou seja, o argumento da defesa de que não há provas suficientes para ensejar condenação não merece prosperar, visto que, além das provas presentes nos autos e testemunhos durante a audiência de instrução e julgamento, o próprio Réu confirmou a ocorrência dos fatos e como eles se passaram, tendo, inclusive, informado que participa do tráfico de drogas há cerca de dois meses.

Assim, as alegações da Defesa, em que pese a elogiável apurada técnica do Doutor Defensor, caem no vazio e em nada alteram a certeza sobre a dinâmica dos fatos e a verdade delituosa ora analisada.

Não obstante, saliento que são indiferentes os argumentos da defesa sobre o Réu ter residência fixa, emprego e possuir 19 (dezenove) anos ao tempo do crime, pois, além de o Réu ser maior de idade, tendo mais do que dezoito anos completos, as demais características não o impediram de cometer o crime, como o próprio Réu alegou.

Com relação ao pedido de restituição do veículo no qual foram apreendidos os entorpecentes (págs. 147/149), observo que, devido ao veículo ser utilizado para fins de traficância, este deverá ser confiscado por força do artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Veja-se Jurisprudência do TJPR.

Ementa

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. tráfico de entorpecentes - art. 33, caput da lei nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ART. 386, INCISO V, DO CPP - não acolhimento - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE INDICAM A CIÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO AO TRANSPORTE DE DROGAS REALIZADO NO CARRO - MENSAGENS DE TEXTO QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE CONLUÍO ENTRE O RECORRENTE E O CORRÉU QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS NA CIDADE - condenação mantida. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO -

CIRCUNSTÂNCIA QUE INDICA SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, O QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO REGIME INICIAL ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM DE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - BEM APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS - CONFISCO POR FORÇA DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto à tipicidade, tenho que é a exata correlação dos fatos de que se ocupa este processo à norma penal invocada na exordial, pouca coisa resta para dizer, já que o acontecido se ajusta perfeitamente à situação criada em abstrato pelo legislador penal, senão vejamos:

Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Quanto ao delito de porte de arma com numeração suprimida, também caracterizado consoante laudo de folhas 186/189, em que foi constatado tanto a numeração suprimida, como o disparo recente e capacidade da arma para tal.

Art. 16 - Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa

§1. Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

De acordo com as Jurisprudências do TJ:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART.16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOIV, DA LEI Nº 10.826/03. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03.

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. 1. Pratica o crime do art.16, parágrafo único, inciso IV, da nºLei10.826/03 quem porta arma de fogo, com numeração removida por processo abrasivo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Não houve dúvida que a arma apreendida estava com o acusado, levando-se em conta o depoimento fidedigno apresentado pelos policiais que participaram da prisão, o qual se amolda às circunstâncias evidenciadas nos autos. Condenação mantida. 3. A perícia indicou a existência de arma com número de série removido por processos abrasivos, fazendo incidir no tipo do art.16, parágrafo único, inc. VI, da Lei 10.826/03. Descabida, portanto, a pretendida desclassificação para o tipo do art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 4. Por conta do entendimento da Súmula 231 do STJ, fica impossibilitado o estabelecimento da pena provisória aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Exatamente o que aconteceu no caso, pois nenhuma dúvida há sobre as condutas ilícitas do Réu, consoante documentos e testemunhos carreados ao bojo dos autos, além, é claro, de sua própria confissão.

Posto isso, passo a dosar a pena aplicável à espécie, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal.

I - PENA-BASE

Considerando e atendendo à culpabilidade do Réu, tenho que não se revestem os fatos praticados de reprovabilidade anormal ou exacerbado, tendo o dolo sido regular ao tipo; aos seus antecedentes, observo que o Réu não os registra (págs. 57/60, 144/146); à conduta social, não se tem nos autos elementos para aferi-la, uma vez que diz respeito tão-só à forma com que o Réu se relacionava com seus pares no meio

em que vivem; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica dos Réus; aos motivos do crime, não há especificação quanto aos motivos que o levou ao delito, possivelmente o lucro fácil, mas tal motivação não é alheia aos delitos do gênero, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor dos Réus; às circunstâncias do crime, observo que foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, mas elementar ao tipo; às consequências do crime de tráfico e associação para o tráfico, são de extrema gravidade, principalmente para os próprios Réus, contudo, tais consequências são inerentes aos delitos dessa natureza, e às consequências do crime, não escapam à normalidade em casos da natureza; e, finalmente, quanto ao comportamento das vítimas, saliente-se que ela em nada contribuiu para esse tipo de conduta delituosa, aliás a coletividade é que é a titular do bem jurídico protegido (saúde pública). Deixo, portanto, de considerar esta circunstância.

Assim, ante a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao Réu, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e multa pecuniária em 500

(quinhentos) dias-multa, para o delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Para o delito previsto no artigo 16, §1, inciso IV, da Lei 10.826/03, fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e multa pecuniária em 10 das-multa.

Cada dia-multa, para ambos, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06).

II - PENA PROVISÓRIA

Passo à análise das agravantes e das atenuantes e fixação da pena provisória, neste sentido, observo que presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual retornam ao mínimo legal, constante da primeira fase (conforme Súmula 231 do STJ).

III-PENA DEFINITIVA

Não há circunstâncias especiais ou gerais capazes de ensejar o aumento ou diminuição da pena até aqui encontrada, pelo que as torno definitivas no patamar fixado na fase anterior.

Saliento que o Réu não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei n. 11.343/06, levando em conta que as drogas apreendidas estavam prontamente embaladas para a venda, quantidade, e o fato de que necessários requisitos cumulativos para a concessão da diminuição, que o agente não se dedique às atividades criminosas, tendo este confessado que se dedicava ao tráfico há cerca de dois meses.

Veja-se, aliás, que se deve levar em conta a forma de acondicionamento de droga apreendida, característico do tráfico contumaz, lembrando que este é atividade complexa, estratificada e organizada, desde o plantio, refino e chegada aos pontos de tráfico, como no caso.

Importante salientar que não foi só o posse da droga para o tráfico, mas também a garantia deste com arma de numeração raspada, inclusive.

Posto isto, inalteradas, as penas da primeira fase, vão definitivas.

DECIDO.

Posto isso, e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na denúncia de páginas 105 a 108, para o fim de CONDENAR o réu GUILHERME DA SILVA SANTOS, já qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e multa pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, para o delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e multa pecuniária em 10 das-multa para o delito previsto no artigo 16, §1, inciso IV, da Lei 10.826/03, sendo para ambos, cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06).

REGIME CARCERÁRIO:

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, conforme antes examinado, do Código Penal, § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, ante a nova redação do §1º, do inc. II, do art. 2º, da Lei 8.072/90, que apesar do art. 1º, inc. I, segunda parte, do mesmo Dispositivo, considerar crime comparado a hediondo o tráfico de entorpecentes, estabelece que a pena deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, de acordo com Lei n. 11.464, de 28 de

março de 2007, então, os cumprimentos das penas se darão dessa forma. Quanto ao que preceitua o art. 387, §2º do CPP, deixo de aplicar neste momento. Isso porque, considerando, o teor do art. 2º, da Lei dos Crimes Hediondos, que diz no § 1º que a pena será cumprida inicialmente no regime fechado, independe do quantum fixado (diferente dos crimes comuns), nada há o que se falar em, dado esse tempo da cautelar, de modificação do regime.

A doutrina de G. de Souza Nucci diz que não se trata de um juízo de execução, o qual haverá de ser feito pelo juiz competente no PEC extraído e encaminhado à VEC ao lá ter.

Vale dizer, conforme tal doutrina, a autorização legislativa é para um exame, quero crer, similar ao de detração, MAS APENAS para verificar o quantum de pena que resta do montante fixado em condenação e assim para observar, se nos termos do art. 33 do Código Penal, o resultante fica inferior a determinado tempo (número de anos), quando não sendo o condenado reincidente e reunidas condições judiciais favoráveis como diz o Código (arts. 59 e 60), pode receber regime mais brando do que indicaria o total inicial absoluto fixado, ou seja, seria, por exemplo, passível um condenado a pena inferior a 8 anos (nesse caso mesmo que superior, descontado o tempo da cautelar, se assim resultasse inferior a 8 anos, aliás, como foi o exemplo doutrinário, se caberia, a critério do magistrado, o regime mais brando, mas não neste que é regime inicial fechado independente da pena, como visto).

Já detração propriamente e progressão, só pode ocorrer na VEC pelo juiz competente que a tudo observará (méritos do condenado, contraditório etc.).

Assim, reservo, conforme a Lei, o exame imediato quanto a isso àquele Juízo, sendo que já será pelo cumprimento dos, em tese, 2/5 ou 3/5 da pena - hediondo - (examinando sobre o comportamento carcerário do condenado e o juízo de progressão/merecimento), pois seria temerário conceder neste momento, em crime que exija o regime mais gravoso, a quem não o mereça pelo eventual mau comportamento, aliás, e se fosse nessa extensão, os poderes do juiz do conhecimento deveriam ser realmente dilargados para a detração e progressão mesmo e ele careceria, ainda, de elementos pelo Estado para a plena aplicabilidade na prática dessa possibilidade, ou seja, a criação de um sistema de consultas on-line para no momento da sentença observar-se eventual falta grave do Réu preso provisório durante a cautela (modo contrário, correria o magistrado risco de, repiso, conceder algo que redunde na soltura imediata do condenado que, por exemplo, tenha liderado rebelião ou mesmo atacado colegas de cela em clara demonstração de abominável comportamento carcerário).

Veja-se decisão no TJSP confirmando entendimento, recurso de decisão deste mesmo prolator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação n. 0009028-

26.2014.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO N. 30.286 - RELATOR IVAN SARTORI:

"...Por derradeiro, o pedido de detração, com vistas a regime mais brando, é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, pese o disposto na Lei 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387 do CPP. É que, para progressão de regime, necessário bem avaliar os requisitos pertinentes, sem falar na possibilidade de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa a princípio constitucional. Nessa linha, julgados desta Casa de Justiça: "(...) embora não se desconheça o teor da Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)."

(Apelação n. 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014); "(...) com relação à detração penal, tem-se que o Juízo de origem ainda não conheceu desta questão. Por esta razão, não se pode, nesta Instância Judicial, suprimir-se, de uma só vez, o devido processo legal (cf. artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), a manifestação do Juiz Natural (cf. artigo 5º, inciso LIII, da CF) e a garantia ao duplo grau de jurisdição (cf. artigo 5º, inciso LV, da CF), sob pena de vilipêndio à Lei Maior do País. Tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a ser produzida no Juízo das Execuções até porque continua vigente o artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei 7.210/1984, a par do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/2012 quando já presentes informações precisas para o exame com a minúcia necessária da situação prisional do acusado, para que repercuta na fixação do regime carcerário" (Apelação n. 0078884-36.2012.8.26.0224, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Roberto Solimene, j. 06.02.2014). Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, encampada sua motivação (art. 252 RITJ). Ivan Sartori - Desembargador Relator".

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Originariamente não se apresentava possível à substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, já que em crimes da espécie a lei especial vedava expressamente, mas foi suspenso pelo Senado esta parte. Ipsis litteris:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Porém, não se apresenta possível à substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, devido à quantidade de pena, que se resultou superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I do Código Penal).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

O crime pelo qual restou condenado o Réu tem vedação expressa do benefício do sursis, independentemente do quantum da pena imposta, a qual na maioria das vezes também impede a obtenção do benefício (art. 44, da lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 e 77, do Código Penal).

DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE:

Considerando que o Réu respondeu a todo o processo preso, convertido o flagrante em preventiva e mantida, assim continuará, conforme é o entendimento correntio da jurisprudência nacional, com mais razão agora que condenado por crime equiparado a hediondo.

Recomenda-se, portanto, o condenado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República).

P.R.I.

Guaratinguetá, 15 de setembro de 2022.